

《【문제3】 공법상 결과제거청구권을 행정소송상 관철할 수 있는 방법에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 결과제거청구권(원상회복청구권)의 행정소송상 관철 방법

I. 문제 제기

- 행정작용이 위법하게 이루어진 경우, 단순히 그 행위를 취소하거나 무효로 돌리는 것만으로는 국민의 권리가 충분히 회복되지 않는 경우가 있다. 예컨대, 위법한 건축허가에 따라 건물이 건축된 상태, 또는 위법한 행정처분으로 인한 기재·등기 상태가 존재할 경우, 신청인은 단순한 취소판결로는 구제받을 수 없다. 이때 위법한 상태 자체를 제거하여 원래의 권리 상태를 회복하려는 권리가 문제되는데, 이를 공법상 결과제거청구권이라 한다. 이하에서는 그 의의와 성질을 검토한 후, 행정소송상 관철할 수 있는 구체적 방법을 설명한다.

II. 결과제거청구권의 의의

1. 개념

- 공법상 결과제거청구권이란 위법한 행정행위나 공권력 작용으로 인해 발생한 상태를 제거하고 원래의 권리 상태로 회복시켜 달라고 행정주체에 요구할 수 있는 권리를 말한다. 이는 단순히 위법 행위의 무효확인이나 취소를 넘어 위법상태를 적극적으로 제거한다는 점에 특징이 있다.

2. 성질

(1) 불법행위 성질

- 일부 학설은 위법한 행정작용을 원인으로 하는 불법상태 제거라는 점에서 민법상 불법행위 책임과 유사하다고 본다.

(2) 위법상태의 제거

- 다른 견해는 손해배상적 성격이 아니라, 단순히 위법상태 자체를 제거하는 것이므로 행정법상 독자적 권리로 본다.

(3) 손해배상청구와의 구별

- 손해배상청구가 이미 발생한 손해에 대한 전보적 구제라면, 결과제거청구권은 현재 진행 중인 위법상태를 종국적으로 제거한다는 점에서 구별된다. 따라서 양자는 상호 보완적 관계에 있다.

III. 행정소송상 관철 방법

1. 항고소송에 병합하여 제기하는 방법

(1) 취소소송과 병합

① 원칙

- 위법한 처분을 취소하는 동시에 그 처분으로 인한 상태 제거를 함께 청구할 수 있다.

② 적용

- 예컨대, 건축허가처분 취소소송에서 허가가 취소되면, 기재된 건축물대장 정정을 병합하여 청구할 수 있다.

③ 한계

- 다만 행정소송법은 주된 청구의 적법성을 전제로 하므로, 취소청구가 기각될 경우 결과제거청구도 함께 배척된다.

(2) 무효등 확인소송과 병합

- 무효확인소송과 병합하는 경우에도 무효확인의 결과로 발생한 위법상태 제거를 청구할 수 있다. 다만 이 경우 역시 주된 소송의 인용 여부에 종속되는 점에서 한계가 있다.

2. 당사자소송으로 제기하는 방법

(1) 의의

- 당사자소송은 공법상 권리·의무의 존부에 관한 분쟁을 다투는 소송이다. 결과제거청구권이 독립된 공법상 권리라면, 이를 기초로 당사자소송을 제기할 수 있다.

(2) 학설

- 긍정설과 다수설은 결과제거청구권을 독자적 공법상 권리로 보고, 당사자소송으로 제기 가능하다고 본다. 부정설은 행정소송법에 명문 규정이 없고, 간접적으로 취소소송이나 손해배상청구로 해결 가능하므로 부인한다.

(3) 판례

- “대법원”은 결과제거청구권을 독자적 공권리로는 보지 않고, 행정청의 작위의무가 명문으로 인정되는 경우에만 구제 가능하다고 하여 소극적 태도를 취하고 있다. 따라서 현실적으로는 당사자소송을 통한 관철은 쉽지 않다.

3. 의무이행소송 도입 시의 가능성 (현행법상 불인정)

(1) 의미

- 의무이행소송은 행정청에게 일정한 행위를 하도록 청구하는 소송이다. 만약 우리 법체계에 의무이행소송이 인정된다면, 결과제거청구권은 직접적으로 이 소송을 통해 실현될 수 있다.

(2) 현행법상 한계

- 그러나 행정소송법은 의무이행소송을 명문으로 인정하지 않고 있어, 결과제거청구권을 직접적으로 행사할 제도적 통로는 제한적이다.

4. 간접강제 또는 손해배상청구 (간접적 구제)

(1) 간접강제

- 법원이 취소판결이나 무효확인판결을 선고하였음에도 행정청이 그 결과를 이행하지 않을 경우, 간접강제 제도를 통해 실질적 권리구제를 확보할 수 있다.

(2) 손해배상청구

- 위법한 상태로 인해 손해가 발생하였다면, 결과제거가 불가능한 경우라도 국가배상청구를 통해 전보적 구제를 받을 수 있다.

IV. 결론

- 공법상 결과제거청구권은 위법한 행정작용으로 발생한 상태를 제거하여 원래의 권리 상태를 회복하고자 하는 권리로서, 손해배상청구와는 구별되는 독자적 기능을 가진다. 그러나 현행 행정소송법상 이를 직접적으로 관철할 수 있는 수단은 제한적이다. 현실적으로는 취소소송이나 무효등 확인소송에

병합하여 간접적으로 실현하는 방법이 주로 활용되고 있으며, 당사자소송을 통한 직접적 관철은 “판례”가 소극적 입장을 취하고 있어 인정되기 어렵다. 장기적으로는 의무이행소송 제도의 도입과 같은 입법적 보완이 필요하다. 현재로서는 간접강제나 손해배상청구를 통해 보완적 구제가 이루어지고 있다. 따라서 결과제거청구권은 제도적 한계에도 불구하고, 국민의 권리구제를 위한 중요한 법리적 기초로 기능하고 있음을 확인할 수 있다.